

1502040-87.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/10/2022
... Rel. Gentil Leite, RT 710/279).

Ainda: "TRÁFICO - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA - OBJETIVO DE COMERCIALIZAÇÃO INDISCUTÍVEL, AINDA QUE SE TRATE DE RÉU DEPENDENTE DA ERVA ENTORPECENTE - CONDIÇÃO DE TRAFICANTE QUE PREPONDERA SOBRE A DE VICIADO, POSTO QUE TINHA ELE O ENTENDIMENTO DA ILICITUDE DO TRÁFICO". (TJSP - Rel. Marino Falcão, RJTJSP 84/382).

Destaco, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
6ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1502040-87.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502040-87.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS MAICK QUEIROZ DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

MATHEUS MAICK QUEIROZ DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, em 13 de junho de 2021, por volta das 21h15min, na Rua Lobo Viana, em esquina com a Rua Doutor Osvaldo Crus, bairro do Boqueirão, nesta Comarca de Santos, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo a terceiros, 3 (três) porções de maconha, pesando cerca de 29,6 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito. Diante das alegações do representante do

Ministério Público (fls. 24/25), bem como da Defensoria (fls. 26/29), foi concedida a liberdade provisória do indiciado, observando algumas medidas cautelares (fls. 30/32).

Laudo toxicológico (fls. 65/67).

Devidamente citado (fl. 39), o réu apresentou defesa prévia (fl. 74). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 (fls. 79/80).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, a título de alegações finais, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da robusta prova de autoria e materialidade do delito. Quanto aos fatos alega que as provas e elementos informativos se harmonizam com o quadro probatório. No mais, a confissão do acusado em sede policial e a forma como se deu sua abordagem não deixa espaço para qualquer argumentação que não relacione a droga ao comércio espúrio. Portanto, é de rigor a condenação do réu pelo artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Diante da primariedade do acusado, a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, pode ser fixada no mínimo legal. Não há agravantes nem atenuantes. Não é o caso da aplicação causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que está demonstrado nos autos pela forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, bem como pelas circunstâncias relacionadas à própria investida policial, que o acusado não era criminoso eventual. Tais circunstâncias evidenciam que a atividade desenvolvida pelo acusado era reiterada e voltada ao sustento, como "profissão" (prática de "delivery"). Em face da quantidade de pena aplicada, o regime inicial da pena pode ser o semiaberto, por expressa disposição legal (fls. 182/186).

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso em concreto não há prova segura de que tenha o réu praticado o crime de tráfico de entorpecentes. Assim, não existindo provas cabais de que o réu tenha praticado o delito descrito na denúncia, é imperiosa a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso remota de condenação, a Defesa requer a aplicação da causa de diminuição da pena; a imposição de regime inicial diverso do fechado, bem como o direito de o réu obter a substituição da pena por restritiva de direitos, já que presentes todos os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal (fls. 189/200).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia que "durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o denunciado na condução de uma bicicleta em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, durante revista pessoal, foi encontrado em seu poder um telefone celular. Em seguida, os policiais vasculharam as imediações, ocasião em que localizaram (03) três porções de maconha no chão, próximas do local onde o denunciado foi abordado.

Questionado a respeito, o denunciado admitiu a propriedade da droga, informando que trabalha como "delivery", fazendo entregas de qualquer tipo de material, inclusive entorpecentes. Disse ainda que pegou o tóxico na Bacia do Macuco, com uma pessoa desconhecida, informando que receberia a quantia de R\$ 5.00 (cinco reais) pela entrega (fls. 08).

É certo pelas circunstâncias da apreensão, modo de embalagem, quantidade de entorpecentes e confissão, que o denunciado visava o comércio ilícito de drogas." (fls. 45/48).

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3), pelo termo de depoimento (fls. 6/7), pelo auto de constatação preliminar de substâncias (fl. 9), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo relatório final (fls. 40/42), pelo exame toxicológico, assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

Cristian Carolino Costa da Silva, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento no bairro do Boqueirão e, no cruzamento apontado na denúncia, o acusado vinha na contramão e, ao ver a viatura, ele tomou a via correta, despertando a atenção da polícia. Resolveram abordar e ele acelerou de bicicleta. Abordaram o acusado na Rua Lobo Viana, na frente da faculdade Santa Cecília. Com ele, nada de ilícito encontraram em sua posse. Ele disse que ia na casa de um amigo. Esse pinote intrigou. A sua colega de farda refez o trajeto do acusado e encontraram as drogas uns cinco ou seis metros deles, que ele confessou a posse e que fazia "delivery", drogas adquiridas no Macuco. Elas estavam embaladas em papel filme, mas soltas. Elas caíram próximas. Disse que estava no meio fio. Em momento algum perdeu ele de vista, apenas quando dobrou rapidamente a esquina. Ele estava com celular, mas disse que pertencia a sua namorada. Um homem ligou várias vezes durante a abordagem. Ele não forneceu a senha de acesso. É raro ver delivery em bicicletas, mais comum em moto.

Amanda Karolina de Sales Santos, Policial Militar, disse que viram o acusado pela Azevedo Sodré e viram o momento em que ele mudou a direção que trafegava. Ele demonstrou nervosismo e acelerou ao ver a polícia. Durante o breve acompanhamento, ele dispensou algo no chão, um breve movimento. Abordado, nada de ilícito estava na sua posse. Vasculhou as imediações, deu alguns passos olhando atentamente. Os entorpecentes estavam no chão, próximo da guia. Seu colega de farda não presenciou ele dispensando provavelmente por estar dirigindo a viatura, concentrado no trânsito. Ele confessou fazer entrega de drogas, mas pouco disse. Ele estava com aparelho celular, que foi apreendido. Não se recorda se tocou durante a abordagem. O acusado não forneceu a senha de acesso.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Matheus Maick Queiroz de Souza, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Nunca trabalhou como delivery de drgas. Trabalha vendendo milho na praia, mas alguns dias trabalha na Metraton, no Canal 6, na Alfaia Rodrigues, com descarregamento de mercadorias. Estava indo comprar maconha, onde tem umas escadas, local que não conhece bem porque, nessa época, estava apenas um ano em Santos. Morava no Humaitá, em São Vicente. No dia estava de bicicleta. Mora na Almirante Tamandaré, em Santos. Perto de sua casa tem uma biqueira, mas vende apenas cocaína e usa apenas maconha. Nesse dia tinha brigado com sua mulher - já a agrediu antes - e, como está mais consciente por conta da Lei Maria da Penha, resolveu sair e comprar a droga para aliviar a mente. Quando estava voltando, os policiais o avistaram e ficou com medo. Dispensou a droga na esquina e continuou andando de

bicicleta. Os policiais o perseguiram e determinaram a sua parada. Mandaram desbloquear o seu celular. Estava escutando música, pausou, mas não conseguiu desbloquear porque o celular era de sua mulher, que adquiriu naquele dia de amanhã. Ela colocou a senha e não sabia qual era. O telefone começou a tocar e pediram para atender. A pessoa não dizia nada com nada, e desligou. Perguntaram a ele se tinha algo de ilícito, o que negou. Os policiais começaram a procurar nos arredores, quando encontraram a droga dispensada por ele. Eles mostraram o pedaço da maconha dispensada e depois mostraram mais três pedaços, que negou ser de sua propriedade. Na delegacia, contou a sua versão dos fatos, assinou os documentos apresentados a ele sem ler por estar tarde, escuro e sem o óculos. Em nenhum momento disse aos policiais que entregava droga em delivery. A droga que dispensou na esquina estava inteira e as drogas que lhe apresentaram estava partida. Mora de aluguel e sua tia o ajuda a pagar. Pegou a droga antes de pagar, pagaria a droga via pix.

Em sede policial, o acusado esclareceu que faz entregas autônomas por não estar cadastrado em nenhum aplicativo e, como precisa se manter, aceita fazer qualquer tipo de entrega sem perguntar o que é. No momento de sua abordagem, quando indagado, informou que pegou a droga no Macuco e ia entrega-la na Conselheiro Nébias, mas não tinha conhecimento do conteúdo da entrega, mas desconfiava (fls. 08).

Já em juízo, o acusado confessou que portava parte a droga apreendida, confessou que realmente e por ele dispensada, mas negou que toda droga localizada fosse sua, droga adquirida para seu próprio consumo.

Com relação a alegação do réu que a droga se destinava ao seu próprio consumo, importante ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28, da Lei 11343/06, restam consumados sempre que a conduta do agente se ajustar, com perfeição, a uma das figuras típicas previstas nestes dispositivos legais.

Seja no tráfico, seja no uso, a conduta do agente de portar o entorpecente restou incontroversa e consumada, restando analisar, apenas, qual o intuito deste porte: o comércio a terceiros ou o consumo próprio.

A comprovação da elementar 'consumo pessoal' exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11343/06, não é circunstância de fácil constatação, devendo ser balizada pela própria situação fática.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, "A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE". (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

E ainda, "PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO É INDISPENSÁVEL A PROVA DO ATO DE COMÉRCIO, PODENDO SER ELE DEDUZIDO DE ELEMENTOS VARIADOS COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, O LOCAL DA INFRAÇÃO ETC." (TJRJ - Rel. Adolphino Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

O acusado confessou que dispensou a droga, cena visualizada pela policial militar, que apreendeu as três porções individuais de maconha, isto é, 29,6 gramas, quantidade e forma de embalagem que, evidentemente, são destinadas a facilitar o tráfico, na medida em que usuários da droga, dificilmente, andam pelas ruas com tantos exemplares unitários.

Pretende convencer que pagou pela droga via pix, embora tenha negado saber acesso ao aparelho celular por ser da sua namorada, que estava na sua posse, usado para escutar músicas.

Nítido expediente de defesa.

No mesmo caminho trilha a jurisprudência: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA E CLORIDRATO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS DROGAS". (TJRJ - Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

Ainda: "IDENTIFICANDO O FORNECEDOR DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, EM PODER DE QUEM FOI APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, PARTE JÁ DIVIDIDA EM DEZENAS DE PAPELOTES, PRONTOS PARA ENTREGA A CONSUMO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, SEM QUE SE POSSA, TODAVIA, RECONHECER ASSOCIAÇÃO COM COMPRADORES". (TJRJ - Rel. Paulo Gomes da Silva Filho - RDTJRJ 20/313).

Assim, a apreensão de quantidade significativa de entorpecente (29,6 gramas) não se amolda à postura de usuários, seja pela dinâmica dos fatos e a fuga confirmada, da sua confissão informal, sua confissão para autoridade policial, é meio de prova, um indício e não uma presunção, indício que, corroborado com outros elementos de prova como a falta de ocupação rentável que lhe garanta a aquisição daquela droga para satisfazer o vício.

Tais elementos permitem a condenação do réu, porquanto permitem crer que seu destino era a entrega a consumo de terceiros.

Com efeito, o artigo 239 do Código de Processo Penal conceitua indício como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o dispositivo acima, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, diz que o "indício é prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator - e principal - a ser observado é que o indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. (...) A indução nos permite aumentar o campo de conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição".

Continua o doutrinador afirmando que "presunção não é um meio de prova, pois constitui mera opinião baseada numa suspeita. É um simples processo dedutivo. Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém relação sexual com menor de 14 anos. Com afirma Bento de Faria, os indícios possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à condenação". (Código de Processo Penal Comentado, página 490, 6ª Edição, Revistas dos Tribunais).

Neste sentido segue a jurisprudência, firme no sentido de que a quantidade do entorpecente, aliada a outros aspectos, é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes, ainda que dependente: "LEVANDO-SE EM CONTA A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADA, O VALOR E O ESCASSO PODER DE COMPRA DO ACUSADO, ALIANDO-SE AO FATO DE QUE LEVARA PARA O LOCAL DE SERVIÇO, TEM-SE QUE ESTÁ CORRETA A CLASSIFICAÇÃO NO ARTIGO 12 DA LEI 6368/76". (TJSP, Rel. Gentil Leite, RT 710/279).

Ainda: "TRÁFICO - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA - OBJETIVO DE

COMERCIALIZAÇÃO INDISCUTÍVEL, AINDA QUE SE TRATE DE RÉU DEPENDENTE DA ERVA ENTORPECENTE – CONDIÇÃO DE TRAFICANTE QUE PREPONDERA SOBRE A DE VICIADO, POSTO QUE TINHA ELE O ENTENDIMENTO DA ILICITUDE DO TRÁFICO”. (TJSP – Rel. Marino Falcão, RJTJSP 84/382).

Destaco, por fim, que a condição de usuário de entorpecente, ainda que reconhecida em exame de dependência química, não tem o condão de afastar a caracterização do tráfico de entorpecentes, notadamente quando é natural a comercialização de drogas pelo usuário para a manutenção do seu vício e que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta e de se autodeterminar.

Demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da Lei 11343/06, passo a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do acusado, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base no seu mínimo legal, cinco (05) anos e quinhentos (500) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal.

A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, deve incidir no caso em concreto, eis que o acusado é primário, ostenta bons antecedentes e não está comprovada a dedicação a atividades criminosas ou que integre os quadros de uma organização criminosa.

Assim, considerando a quantidade da droga, reduzo a pena em dois terços, totalizando a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu MATHEUS MAICK QUEIROZ DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e a pena de dez dias-multa, que deverá ser somada a originariamente aplicada.

Concedo o réu o direito de recorrer em liberdade em razão da sua colaboração com a justiça ao longo da instrução.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

P.I.C.

Santos, 07 de outubro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA